

1501227-25.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/06/2022

... reafirmaram o entendimento de que, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, estaria autorizado, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501227-25.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501227-25.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2230796/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 13646876 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 7064/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2230796 - 05º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 7064/20/429 - 05º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Teixeira Molina e outro

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

GABRIEL TEIXEIRA MOLINA e ALEX SANDRO DOS SANTOS FEITOSA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, c/c. artigo 61, inciso II, alínea "j", e artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 20:50h, na Rua Luísa Mazeto de Araújo, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia da COVID-19, armazenaram e mantiveram em depósito, com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 8,03g de cocaína em forma de 'crack', substância entorpecente, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram presos em flagrante delito, mas foram beneficiados com a

liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 85/87).

Em seguida, os réus foram notificados (fls. 137 e 139) e apresentaram defesas preliminares (fls. 131/133 e 145).

A denúncia foi recebida aos 20 de abril de 2021 (fls. 146).

Folhas de Antecedentes e certidões de eventos foram juntadas aos autos (fls. 63/70).

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Renato Sandro Cicutti e Marcos Henrique Cândido de Oliveira. Após, os réus foram interrogados.

Em memoriais, a d. representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 249/256).

A r. Defesa do réu Gabriel, a seu turno, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, com a fixação do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 261/262).

Já a i. Defesa do corréu Alex Sandro sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas em razão da violação de domicílio por parte dos policiais. Quanto ao mérito, bradou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 e pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (fls. 266/284).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 15/18), termos de depoimentos (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), fotografias (fls. 22/24), laudo de constatação (fls. 27/31), depósito do numerário apreendido (fls. 109), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 194/196 e 202/204) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, o réu Alex Sandro dos Santos Feitosa negou qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Alegou que apenas havia autorizado que Gabriel embalasse das drogas em sua residência, informando que, em troca, receberia uma certa quantidade de crack para seu uso.

Por sua vez, o réu Gabriel Teixeira Molina, ao ser interrogado em Juízo, relatou que havia pedido ao corréu Alex Sandro para utilizar sua residência para embalar a droga. Disse que, após chegar ao local, deu três pedras de crack para o corréu Alex Sandro consumir e foi para o quarto. Contou que, cerca de 10 minutos depois, foi surpreendido pelos policiais militares, que o observavam pela janela no momento em que estava cortando e separando o entorpecente.

Já os policiais militares Renato Sandro Cicutti e Marcos Henrique Candido de Oliveira relataram que, durante um patrulhamento de rotina, foram informados por um pedestre que estaria ocorrendo o empacotamento de drogas no endereço em questão. Contaram que, assim que chegaram ao local, avistaram por uma janela ambos os réus embalando a droga, momento em que resolveram ingressar na residência. Informaram, ainda, que, durante a abordagem, encontraram R\$ 5,00 em poder de Gabriel, além de dois telefones da marca Samsung e uma balança de precisão. Disseram que, na ocasião, Gabriel admitiu a propriedade dos entorpecentes e alegou que estava no local apenas para embalar a droga. Já Alex alegou que teria emprestado sua casa para que a droga fosse embalada e que, em contrapartida, receberia certa quantidade de crack para seu uso. Relataram que, na sequência, deslocaram-se até a residência de Gabriel e, com a anuência de sua genitora, entraram no local, onde encontraram outro aparelho de celular Samsung e a quantia de R\$ 262,00 em espécie.

Pois bem. Como se vê, a confissão apresentada pelo réu Gabriel encontra-se em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com o laudo químico-toxicológico acostado às fls. 194/196 e 202/204 e com os depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares.

Já a versão apresentada pelo acusado Alex Sandro não convence, haja vista que, muito embora o referido réu alegue que os entorpecentes apreendidos em sua

residência pertenceriam apenas a Gabriel e que teria somente emprestado sua casa para que este embalasse a droga, os policiais militares afirmaram de maneira categórica que, antes de ingressarem na residência, visualizaram através de uma janela que ambos os réus estavam no mesmo quarto embalando a droga. Aliás, nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Da mesma forma, não prospera a tese de que as provas seriam nulas em razão da violação de domicílio por parte dos policiais. Assim concluo porque, apesar da existência de alguns julgados em sentido contrário da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, tanto a 5ª Turma deste mesmo Tribunal quanto a 1ª Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal, em decisões recentíssimas, reafirmaram o entendimento de que, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, estaria autorizado, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes.

3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.

6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF -1ª Turma - Ag. Reg. no RHC nº 213.852/RJ - Relª. Min. Rosa Weber - D.J. 30/05/2022)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. FUGA DO AGENTE, TENTATIVA DE SE LIVRAR DAS DROGAS E RESISTÊNCIA À PRISÃO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, MUNIÇÕES, PETRECHOS DO TRÁFICO, SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO. INGRESSO DOMICILIAR. HIPÓTESE LEGAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

II - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram o recorrente portando uma mochila conversando com uma pessoa dentro de um carro. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os agentes empreenderam fuga, tendo o

recorrente adentrado sua casa e atirado a mochila para o terreno vizinho. Ao ser alcançado, o recorrente ofereceu resistência, ao passo que sua mochila foi recuperada, na qual foram encontrados "R\$ 15.956,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais); uma caixa contendo 50 (cinquenta) cartuchos intactos do calibre 5.56 (munição de fuzil); 04 (quatro) balanças de precisão; anotações diversas relacionadas ao tráfico de drogas, em 14 (quatorze) folhas; 311 (trezentos e onze) microtubos plásticos, tipo eppendorf, contendo cocaína; 252 (duzentos e cinquenta e dois) pedras de crack; 343 (trezentos e quarente e três) gramas de cocaína a granel em uma embalagem; 115 (cento e quinze) gramas de cocaína em duas embalagens; seis porções menores de cocaína, que totalizaram 18 (dezoito) gramas; 02 (duas) pochetes vazias; 03 (três) rolos de papel filme utilizados em embalagens de drogas e 01 (uma) máquina de cartão". Na mesma esteira, o v. acórdão objurgado reforça que "O auto de prisão em flagrante revelou que os dois policiais, que efetuaram a prisão, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente, o qual, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga, vindo a entrar na sua casa, resistindo à prisão. Certo é que a inviolabilidade do domicílio não é direito absoluto, prevendo a própria Constituição da República hipóteses em que é possível a entrada em residência sem o consentimento do morador, dentre as quais se destaca o caso de flagrante delito. [...] Esta é exatamente a hipótese retratada nos autos, de modo que não se configura a alegada invasão de domicílio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

III - Ao contrário da sustentação defensiva de que "pouco importam" as atitudes do agravante que ensejaram a atuação policial, reforça-se que, não só pela importância da devida tutela jurisdicional no caso em exame, mas também pela compreensão mais ampla acerca da formação social e jurídica que permeia a sociedade brasileira e das regras de convivência que organizam as relações humanas e sociais, as normas penais e processuais penais tutelam os bens jurídicos mais importantes e as fundadas suspeitas de prática delitiva ensejam, por autorização constitucional, a atuação das forças de segurança que tem, por atribuição da própria Carta Magna, o dever de proteção e tutela dos bens mais valiosos da sociedade.

IV - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso domiciliar, consistentes na fuga e no arremesso da mochila, comportamentos concretos a ensejar fundadas razões para a atuação policial, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de variadas formas de apresentação da cocaína, além de petrechos do comércio espúrio, munições e expressiva quantia em dinheiro, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio e da escorreita atuação policial.

V - Ademais, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido."

(STJ -5ª Turma - Ag. Reg. no RHC nº 164.149/SP - Rel. Min. Jesuíno Rissato - D.J. 24/05/2022).

No caso dos autos, inclusive, há que se destacar que, ao contrário do que sustenta a r. Defesa, o ingresso na residência se deu não apenas com base em uma denúncia anônima mas também, e especialmente, pelo fato de os policiais terem visualizado, através de uma janela do imóvel, ambos os acusados fracionando e embalando o entorpecente, o que, obviamente, caracterizaria a hipótese de flagrante de crime e, por conseguinte, autorizaria o ingresso na residência independentemente de consentimento ou morador ou de mandado judicial.

Diante de tais circunstâncias, não havendo dúvidas acerca da participação de ambos os réus no embalo das drogas apreendidas, que segundo o próprio réu Gabriel seriam destinadas à comercialização, é de rigor a condenação dos acusados pela prática do

crime de tráfico de entorpecentes, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, observo que os réus não registram antecedentes criminais e que a quantidade de droga apreendida não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que a fixo em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, valendo destacar que não se mostra aplicável a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, uma vez que, muito embora o crime tenha sido praticado durante período de pandemia, não restou demonstrado que os agentes se beneficiaram de tal circunstância para terem sua ação facilitada, especialmente porque o delito ocorreu no interior da própria residência.

Já na terceira fase, considerando que os réus são primários e de bons antecedentes e que não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou que integrem organização criminosa, reduzo a pena até então aplicada em 2/3, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resultando na pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO os réus GABRIEL TEIXEIRA MOLINA e ALEX SANDRO DOS SANTOS FEITOSA à pena individual de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente.

Estando presentes, porém, os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela pena de prestação de serviços à comunidade, a ser indicada na fase de execução, e por mais 10 dias-multa, sem prejuízo da multa originária.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Considerando que os réus responderam ao processo soltos e, ainda, diante da substituição da pena privativa de liberdade, concedo aos acusados o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiverem presos.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 262,00) às fls. 19/21 em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condeno os réus, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 12 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA